

1500902-65.2021.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... O réu foi condenado anteriormente por tráfico e não existe outro dono da droga, sendo mendaz e fantasiosa a alegação do réu de que a droga pertenceria ao seu tio. Diante da quantidade de drogas apreendida, encontro de anotações de tráfico e depoimentos colhidos em juízo, sustenta a procedência da denúncia. Requer o aumento da pena base pela quantidade e variedade de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500902-65.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500902-65.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321467/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 21608252 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 1878/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2321467 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL HENRIQUE SANTOS PEDRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Rafael Henrique Santos Pedro, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 15h00, na Rua Henrique Trinca, nº 186, Vale do Redentor II, nesta cidade e comarca, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega e fornecimento a

terceiros, 232 (duzentos e trinta e dois) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 237,60g (duzentos e trinta e sete gramas e sessenta decigramas), 231 (duzentos e trinta e uma) porções de crack, pesando 79,36 (setenta e nove gramas e trinta e seis decigramas), e 01 (uma) porção de maconha, pesando 14,82g (quatorze gramas e oitenta e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 107/109 veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/125.

O réu foi notificado (págs. 157) e apresentou defesa preliminar (págs. 163/165), sustentando, em síntese, que é apenas usuário e não comercializa os ilícitos. Requer, para fins de atestar sua condição de usuário, que seja instaurado o incidente de dependência toxicológica. Requer a absolvição do denunciado. Apresentou rol de testemunhas.

A denúncia foi recebida aos 26 de janeiro de 2022, oportunidade em que fora designada audiência de instrução (págs. 168/170).

Audiência de instrução iniciada aos 23 de março de 2022 - pgs. 309/310 e concluída aos 18 de maio de 2022 - pgs. 362/363. Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo e mídia anexada ao SAJ.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em memoriais o representante do Ministério Público postulou pela condenação do réu. Expôs a prova oral coligida e concluiu que a negativa do réu encontra-se isolada. Reputa inconcebível que a droga tenha sido implantada pela polícia para forjar o réu. O réu foi condenado anteriormente por tráfico e não existe outro dono da droga, sendo mendaz e fantasiosa a alegação do réu de que a droga pertenceria ao seu tio. Diante da quantidade de drogas apreendida, encontro de anotações de tráfico e depoimentos colhidos em juízo, sustenta a procedência da denúncia. Requer o aumento da pena base pela quantidade e variedade de drogas, além da personalidade do agente, voltada para a prática delitativa. Embora seja relativamente menor é reincidente. Requer o afastamento da minorante e imposição do regime fechado - pgs. 370/382.

A defesa, por sua vez, alega que a prova é insuficiente para a condenação. Alega que as imagens apresentadas não identificam o réu (imagem 1), ao passo que a imagem 2 apenas indica um indivíduo abaixado. A imagem 3 não traz informações que não foram confirmadas em juízo, pois o réu confirma que frequenta o local e conhece "João Modesto". Aponta contradição no depoimento de Florence, pois teria dito que não conhece os moradores da casa, mas afirmou que eles não tem muita parada, ficam por ali. A genitora do réu não viu o momento em que os policiais encontraram a mochila com as drogas, pois foi deixada no quintal. Alega que Lidiane negou-se a assinar documentos sobre uma queda de moto de Rafael, pois seriam informações falsas. Questiona o fato de Florence ter retornado a residência sem qualquer documentação formal de tal diligência. Tece considerações sobre o ferimento nas nádegas do réu, concluindo que os policiais agem de forma desesperada, inclusive tentando fazer a genitora do réu afirmar algo que não tinha conhecimento. Sobre a propriedade das drogas, alega que não há provas de que o réu concorreu para a infração penal, pois o tio de Rafael é envolvido com o tráfico de drogas e na época estaria residindo na propriedade. Sobre as anotações não há provas de que foram feitas por Rafael. Alega que o tio de Rafael carrega ostensiva ficha criminal por

tráfico de drogas e que assim como o tio, Rafael não se encontrava na residência naquele momento. Em síntese, a defesa alega que não há o mínimo de certeza sobre a propriedade da droga. A droga foi encontrada em ambiente de livre acesso, em um local em que moram mais de quatro pessoas e ainda, inclusive, um dos moradores, também proprietário do imóvel, vive em constante problema com drogas e é conhecido pela traficância local. Requer a absolvição na forma dos incisos V e VII do art. 386 do CPP. Alternativamente, requer a fixação de pena sem consideração da personalidade do agente e indica a atenuante da menoridade relativa, conforme pgs. 405/414 e documentos que acrescentou nas pgs. 415/416.

DECIDO.

1 -) QUESTÃO PRÉVIA

Nas pgs. 164 a d. Defesa requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica do réu.

Verifica-se, no entanto, que o réu, interrogado, respondeu com clareza às indagações deste magistrado, do Ministério Público e Defesa, de modo que nada evidencia que tenha sua capacidade de discernimento comprometida pelo uso de entorpecentes.

O art. 149 do CPP preceitua que somente a dúvida relevante acerca da integridade mental do acusado legitima a realização de exame de dependência toxicológica, para fins de constatação de insanidade mental.

Assim, inexistindo indícios de que o réu sofreu redução na sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme esse entendimento, justificado se encontra o indeferimento do pedido de realização de incidente de dependência toxicológica, o qual, uma vez deferido, representaria, provavelmente, produção de prova meramente protelatória.

Nesse sentido a jurisprudência: "A tão só alegação de ser o réu consumidor reiterado de drogas não torna obrigatória a realização do exame de dependência química, mas cabe ao Juiz, a partir da análise do acervo probatório e das circunstâncias do crime, avaliar a conveniência e necessidade do ato." (STJ, Quinta Turma, HC 118970, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 07.02.2011)", "O juiz pode indeferir o pedido de instauração de incidente de Dependência Toxicológica, em decisão fundamentada, demonstrando as razões pelas quais considera dispensável a sua realização (APR nº 20160910037182 (980891), 3ª Turma Criminal do TJDF, Rel. Sandoval Oliveira. j. 17.11.2016, DJe 21.11.2016)".

Com tais fundamentos, indefiro a instauração do incidente.

2 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

2.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 12/14), pelo auto de constatação preliminar (págs. 19/21), bem como pelos laudos periciais de págs. 135/146.

Tais documentos demonstram a massa líquida dos ilícitos, além de todos os objetos e a quantia em dinheiro apreendida na operação precedida de regular expedição de mandado judicial.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2.2 -) Das provas da autoria.

Florence Ribeiro Gallego Gomes, em juízo, disse que alguns dias antes do cumprimento do mandado de busca e a apreensão na casa dele foi preso João Modesto, nas proximidades da casa do réu. Logo após essa prisão, populares entregaram uma gravação que dizia quem estava fazendo a entrega de drogas na cidade. Identificaram o João Modesto e o Rafael, vulgo Nescau, que chega até uma árvore, enterra uma droga e aponta para o João Modesto. Nisso o João Modesto foi preso em flagrante. Tinham informações de que o Rafael guardava a droga rapidamente em casa e já levava para as biqueiras. A casa dele foi alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão pela DIG de Casa Branca. Ele foi abordado num bar e de posse de um mandado de busca encontraram uma mochila com as drogas, dinheiro e anotações. O réu recebeu voz de prisão. O réu negou a propriedade da mochila, mas a mãe disse que era dele. Além dele e da mãe, mora um irmão pequeno e um irmão mais velho que mora nos fundos. Naquela residência não pairava suspeita sobre mais ninguém. Não conhecia os familiares do Rafael antes dos fatos. Ficou sabendo no dia, porque conversaram com a mãe do réu e ela deu as explicações. O Rafael disse que foi arrastado pelos policiais e ficou com as nádegas lesionadas, mas ele tinha caído de moto no domingo anterior. A mãe disse que ele caiu de moto e estava com lesão nas nádegas infeccionada. Foram na casa da mãe dele para perguntar se ele tinha ido no hospital no dia do acidente de moto. A mãe também se recusou a depor no sentido de que ele teria caído de moto. Posteriormente, ficou sabendo que ela foi na delegacia.

João Paulo Gonçalves Parra, em juízo, disse que anteriormente a esta data tinha feito uma prisão na praça, do João Modesto e populares entregaram imagens de pessoas, inclusive do Nescau que era o "disciplina" do bairro. Pegou as imagens e passou para a polícia civil, entregando ao Delegado Dr. Cristiano. Foi requerido um mandado de busca e apreensão e no cumprimento a policial civil Florence achou as drogas. O "disciplina" é o cara que fiscaliza o movimento dos outros traficantes menores. Eles são os caras que corrigem os outros traficantes menores, subordinados. Eles estão entre os gerentes e os vapores. Informa que o réu foi conduzido ao PS e não queria retirar as calças perante a médica. Ele disse que tinha sofrido um acidente de moto e não queria mostrar as nádegas para a médica. Ele foi submetido a outro exame que teria constatado que as lesões estavam em estado cicatricial e não seriam daquela situação.

Lidiana, testemunha de defesa, mãe do réu. Tinha chegado do hospital. Estava internada e chegou por volta de meio-dia e pouco. Estava deitada no sofá, ainda estava medicada. Chegou um policial e avisou que entrariam na casa. Disse que não tinha problema que poderiam entrar. Uma mulher loira entrou na casa, mexeu nas coisas. Não conhecia os policiais, mas eram inúmeros. Mandaram a depoente ir para o quintal e lá permaneceu. Estava deitada no sofá e não viu o Rafael. Depois de algum tempo falaram que tinham achado droga em cima do video-game do filho da depoente. A revista começou na sala. Não sabe o que dizer. Mostraram um mochila para a

depoente. Dentro da mochila tinha uma sacola. O policial perguntou se a bolsa lhe pertencia e disse que não. Falaram que acharam o mochila ali. Seu filho mais velho chegou. Os policiais disseram que a bolsa era de um dos três. Foram para a delegacia. A mochila estava em cima de um vídeo-game que estava sobre a estante. Antes da polícia chegar não tinha mochila lá. Estava deitada no sofá. Não sabe se o Rafael caiu de moto naqueles dias. Ficou internada uns 25 dias praticamente. O Rafael ajudava no corte de cabelo 10. Ele ficava lá ajudando. Depois do flagrante, a moça do cabelo loiro falou que a depoente tinha que ir na delegacia assinar papéis. Falou que não ia porque estava muito triste com eles porque tinha uma caixa de brinquedo lá com uma arminha de brinquedo e eles postaram no facebook. Por causa disso foi chamada na escola da criança. Eles levaram um papel pronto para a depoente assinar. Na primeira vez não tinha papel. Na segunda vez eles vieram com um papel na mão e falou para a depoente assinar. Havia motocicleta na casa. Há algum tempo atrás havia motocicletas velhas que foram deixadas na casa da depoente por um amigo dele. Não sabe quem é o dono. Dentro da casa havia mais ou menos uns 8 policiais. Sua casa fica na frente e tem uma casa no fundo. Eles não foram na casa dos fundos. Eles foram em bastante pessoas. Não estava muito ativa porque tinha acabado de chegar do hospital.

O réu, Rafael Henrique Santos Pedro, em seu interrogatório, afirmou que está tudo tranquilo na prisão. Fez 21 anos dia 10. Trabalha como barbeiro. Estudou até o primeiro colegial. Está estudando na prisão. Foi preso em 2019 pelo João Paulo mesmo, mas foi colocado em liberdade. Sua mãe está com câncer e seu tio mora na casa. Ele acabou de sair da cadeia. Mora todo mundo junto. Nessa semana, estava levando seus irmãos na escola porque o irmão mais velho sai para trabalhar e o depoente fica responsável por abrir a barbearia. Levou os irmãos na escola, tomou café e abriu a barbearia às 08:00. É aprendiz. Varre o chão, passa pano e corta alguns cabelos. Estava conversando com seu patrão e viu parando um gol prata na porta da sua casa e alguém entregou uma "situação" para o seu tio. Seu patrão falou para que ficasse esperto com seu tio que ele poderia arrastá-lo em alguma situação. Falou para seu patrão que seu tio tinha parado com tudo. A viatura abordou dois moleques de moto. Quem abordou foi o João Paulo. Conhece o João Paulo porque ele falou que ia acabar com a sua vida. João Paulo lhe algemou e falou que estava preso. Sentou-se no chão e falou que enquanto não dissesse o motivo de estar preso não iria levantar. Arrastou o depoente uns 5 passos e começou a doer. Resolveu levantar. Colocou a mão na bunda e viu que estava sangrando. Foram até a casa do depoente. Sua mãe chegou num Uber. Ela tinha acabado de chegar do hospital, de alta. Ela conversou com os policiais e foram lá com um mandado e entraram. Ninguém lhe tirou da viatura. Mandaram ficar sentado numa cadeira, mas falou que não queria sentar. Eles apresentaram a bolsa. Disse que não tem apelido de "Nescau". O apelido é do seu tio. Ele vende drogas lá. Sua avó tenta internar ele, mas ele não tem jeito. A casa também é dele e ele fala que vai colocar fogo na casa. O João foi na porta da sua casa brigar com seu tio. O João falou que o tio estava com uns negócios que era dele. Até falou para o João que tem irmão pequeno, sua mãe está com câncer e não queria. Seu tio se chama Lucas da Costa dos Santos. Ele foi preso. Faz pouco tempo que ele está na rua. Ele tem uma namorada e fica na casa dela. Ele ficou 6 ou 7 anos de cadeia e descobriu que ela tinha traído ele e foi morar na casa com o depoente. Sua avó sabia que as drogas eram dele. Ele foi internado e fugiu da internação e que está na casa novamente. Não caiu de moto. Não tem moto. As duas motos apreendidas na casa, uma é do seu tio e outra é do amigo dele - caveirinha (Marquinho). Alega que está preso injustamente e que seu tio é quem tinha que estar preso. O João Paulo tem uma intriga com o depoente desde o finalzinho de 2018. Ele falava que pessoas como o depoente têm que morrer na cadeia. Quem estava vendendo drogas na praça era "um bando de pretinho". Mora de esquina com a praça. Para ir buscar seus irmãos na escola ou ir em qualquer lugar tem que passar na praça, mas ele (João Paulo) não entende. As motos não lhe pertencem e o celular também não era seu. As anotações também não eram suas. Pouco antes parou um gol prata lá e entregou coisas para seu tio. Seu tio tem envolvimento com droga, todo mundo sabe. Ele xinga o depoente e ameaça bater no

depoente. Conhece o João Modesto e ele estava discutindo com o tio do depoente.

3 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos.

Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada." (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a "lei do silêncio", extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

Nada faz crer que os policiais pudessem ter consigo 232 (duzentos e trinta e dois) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 237,60g (duzentos e trinta e sete gramas e sessenta decigramas), 231 (duzentos e trinta e uma) porções de crack, pesando 79,36 (setenta e nove gramas e trinta e seis decigramas), e 01 (uma) porção de maconha, pesando 14,82g (quatorze gramas e oitenta e dois decigramas), para indevidamente "forjar" cidadãos, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar pessoas com as quais não mantêm qualquer desafeto ou problema pessoal.

Segundo os policiais, a própria mãe do réu teria dito que a mochila apreendida (onde estavam as drogas), pertencia ao réu.

Como bem argumentado pelo Ministério Público "o encontro da mochila contendo drogas na casa do réu não foi aleatório. A partir da prisão de João Modesto, a polícia militar tomou conhecimento, através de imagens fornecidas por populares à polícia, que Rafael quem havia fornecido as drogas para que João Modesto exercesse o tráfico no local. Na sequência, foi expedido mandado de busca para a residência dele visando o encontro das drogas. Em nenhum momento chegou ao conhecimento da polícia qualquer relação do suposto tio Lucas com as drogas fornecidas a João Modesto." (pgs. 377).

A respeito da referência supra aos argumentos acusatórios, abra-se breve parênteses, pois é prudente consignar que é pacífico no âmbito do STF e do STJ o entendimento de ser possível a fundamentação per relationem ou por referência ou por remissão, não se cogitando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal) (E. STF: MS 27350 MC/DF, Relator Min. Celso de Mello, DJ de 04.06.2008; Emb. Decl. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 692.087/DF, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 12.08.2014, unânime, DJe 29.08.2014 e no STJ: REsp 1.426.406/MT, Rel. p/Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11.05.2017).

A tentativa de imputar a terceiro, no caso, ao tio Lucas, a propriedade da droga não se coaduna com o contexto fático que permeou a apreensão das drogas e a identificação feita pela genitora do réu perante a policial Florence de que a mochila pertencia ao réu.

A genitora do réu, testemunha descompromissada, não chegou a imputar a propriedade das drogas ao irmão (tio de Rafael), Lucas.

Valendo-se novamente dos argumentos acusatórios, por serem mais convincentes, tem-se que "O tal tio Lucas não estava no local e, durante o cumprimento do mandado, sequer foi ventilado que ele morava ali, aliás as investigações anteriores sobre o tráfico nem cogitaram o envolvimento desta pessoa."

Embora a defesa também argumente que Rafael também não estava no local, o que é verdade, tem-se que toda a diligência foi desencadeada tendo Rafael como foco. Não havia outro suspeito no local e não há provas de vinculação de Lucas a João Modesto, pessoa cuja prisão constitui o fiat lux que direcionou a ação da polícia ao comparsa deste, no caso, o réu Rafael, vulgo "Nescau".

O próprio réu, em seu interrogatório, afirmou que disse ao seu patrão que "seu tio parou com tudo", ou seja, que após a saída de Lucas da prisão, não haveria o envolvimento de Lucas com outros ilícitos.

Conforme artigo 156 do CPP "A prova da alegação incumbe a quem a fizer [...]". Portanto, não se trata de qualquer inversão do ônus da prova, mas sim de aplicação da dinâmica probatória imposta pelo devido processo legal.

Não há provas que vinculem Lucas à mochila, de modo que a tese defensiva não contém lastro. O patrão do réu "Anderson", que teria visto um carro deixando algo para o tio de Rafael não foi arrolado como testemunha, o que sugere ser meramente retórica a linha autodefensiva sustentada pelo réu.

Diversamente, o acervo probatório direciona a propriedade das drogas para Rafael.

O Art. 239 do CPP prevê : Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Nos dizeres de Malatesta "Os indícios não merecem, certamente, uma apoteose, mas também não merecem a excomunhão maior."

A conclusão obtida neste Juízo é a de que neste processo há indícios graves, precisos e concordantes, hábeis a respaldar o raciocínio indutivo-dedutivo acerca da culpabilidade de Rafael pelo crime descrito na denúncia.

Como visto, Rafael estava vinculado a João Modesto e a polícia identificou Rafael, vulgo "Nescau" como sendo o "disciplina" do bairro, além de ser o responsável por abastecer as "biqueiras".

A ligação entre Rafael e João Modesto é admitida pela própria defesa ao consignar que "A imagem 3 também não traz informações que não foram confirmadas em juízo pelo réu, uma vez que, assumiu frequentar o local e conhecer e manter contato com "João Modesto". (pgs. 408).

A partir de tais laços, a polícia empenhou esforços no sentido de realizar busca e apreensão, devidamente autorizada judicialmente, para reunir elementos de prova contra Rafael. Nesse esforço teria encontrado a mochila que, segundo a prova testemunhal, foi identificada pela própria mãe de Rafael como pertencente a ele.

Em que pese o esforço defensivo que logrou demonstrar pelas certidões de pgs.

399/400 que Lucas da Costa Santos, tio de Rafael, ostenta condenações por tráfico, é inegável que o réu também é reincidente específico, conforme pgs. 46/48.

Descortinado tal cenário, inclina-se o fiel da balança no sentido da tese acusatória, pois o réu possui know-how no ramo da mercancia de drogas e a prova dos autos é suficiente para autorizar a conclusão de que, embora anteriormente condenado pelo mesmo delito, permaneceu no "ramo".

Além da lição acerca do valor da prova indiciária, calha trazer à colação outros ensinamentos de FRAMARINO DEIMALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 destaques do Juízo)

À luz de tais diretrizes, as alegações defensivas de insuficiência de provas não ecoam no espírito deste julgador a ponto de que seja possível fundamentar veredito em sentido oposto à pretensão ministerial, pois o panorama probatório evidencia completa ausência de contraprovas capazes de indicar a propriedade de terceiro sobre as drogas apreendidas.

Com efeito, não se ressenete este Juízo de qualquer dúvida razoável a respeito da procedência da ação penal.

Presente a tipicidade delitiva na forma capitulada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Por fim, sobre a lesão nas nádegas do réu, este Juízo adotou as providências que lhe competiam, conforme termo de audiência de custódia - pgs. 55 e 61.

Eventual abuso policial durante a prisão não modifica a conduta criminosa praticada, sendo certo que o réu guardava grande quantidade de entorpecentes em sua residência que não se destinavam ao seu uso pessoal e exclusivo.

4 -) DO VEREDITO E DOSIMETRIA DA PENA

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 107/109, para CONDENAR RAFAEL HENRIQUE SANTOS PEDRO pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu

evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas recomenda acréscimo, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06, pois a apreensão foi de 37,84g de cocaína, 12,44g de maconha, 42,45g de cocaína e 24,81g de cocaína, conforme apontado nos laudos de pgs. 135/146.

A soma das substâncias totaliza 117,54 gramas, quantidade-massa superior às apreensões ordinárias que ocorrem nesta comarca.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Foram apreendidas substâncias diversas, cocaína, crack e maconha, evidenciando maior periculosidade do traficante que possui à sua disposição variada gama de entorpecentes, pois estaria apto a atender "clientela" diversificada.

Assim, pelo disposto no art. 42 da Lei de Drogas, impõe-se ligeiro acréscimo na reprimenda.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias, notadamente pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, majoro em 1/6 a pena base para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

O réu é reincidente específico, pois condenado definitivamente nos autos do processo ° 1500664-17.2019 cujo trânsito em julgado operou-se aos 07.07.2020. Todavia, diante da menoridade relativa, abstenho-me de qualquer acréscimo na segunda etapa.

Presente a agravante do art. 61, II, "j", Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do Covid-19. A calamidade pública sanitária persistia no país e no Estado de São Paulo na época dos fatos (25.11.2021) em escala ainda mais grave do que quando a calamidade foi decretada. Portanto, a realidade não havia alterado, ou melhor, deteriorou-se.

Há perfeita correlação entre a agravante e a conduta praticada pelo réu. O tráfico de drogas ataca exatamente a saúde pública, mesmo bem jurídico que estava sendo violentamente prejudicado pela pandemia COVID-19 em novembro de 2021.

Agravo a pena em 1/6 fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680

dias-multa.

O réu não faz jus à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois é reincidente específico.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada e à reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c.c. art. 59, todos do Código Penal.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Tendo em vista o montante de pena aplicado, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, conforme já fundamentado, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Fica a cobrança suspensa na forma do § 3º do art. 98 do NCPC c.c. art. 3º do CPP, pois o réu foi patrocinado por advogada dativa, de modo que defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do réu, mantenho sua custódia cautelar, indeferindo a pretensão de apelar em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Patrocinado por advogada dativa, arbitro os honorários, conforme regras do convênio OAB-DPE. Oportunamente, expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

- 1 -) Expeça-se guia de execução definitiva;
- 2 -) Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;
- 3 -) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
- 4 -) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;
- 5 -) Decreto o perdimento dos valores apreendido R\$ 152,00, os quais serão revertidos em favor do FUNAD, dado que a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva.
- 6 -) Destrua-se o entorpecente armazenado para fins de contraprova.

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA